第 10 章

債権の回収

第1節　債務者の協力を得て行う債権の回収
第2節　債務者の協力を得られない場合の債権の回収

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　債務者の協力を得て行う債権の回収

この節で学ぶこと

　債権者は、債務者が債務を履行しない場合、様々な法的手段を講じて債権を回収する必要が生じる。この節では、債権回収をする必要が生じた場合に採り得る法的手段とそのポイントについて説明する。

3級の学習項目

　債権の消滅事由（弁済・代物弁済・供託・相殺・更改・免除・混同）、時効、緊急時の債権の回収

3級の復習

　債権の消滅事由には、様々なものがある。その主なものは、次の通りである。

Ⅰ 内容の実現による債権消滅事由	
①弁済	債務の本旨に従った履行がなされること。
②代物弁済	本来の給付に代えて別の物を給付し、それによって債権を消滅させること。 債権者と債務者の代物弁済契約による。
③供託	弁済の目的物を供託所（法務局）に寄託すること。目的物は債権者の下に置かれるわけではないが、供託が行われることで債務者は債務から解放され、債務者に対する債権は消滅する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅱ 実現が不要となることによる債権消滅事由	
①相殺	債務者が債権者に対し、自らも同種の債権を有している場合に、その債権と債務を対当額で消滅させること。相殺は、一方の意思表示だけでできることができ、その意思表示が相手方に到達すると効力が生じる（債権は消滅する）。
②更改	新たな債権を成立させることにより、前の債権を消滅させること。
③免除	債権者が債務者に対して、その債権を放棄することにより消滅させること。債権者の一方的な意思表示でできることができる。
Ⅲ その他の債権消滅事由	
①消滅時効	債権者が権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、債権そのものが消滅する事由。消滅時効の完成により債権が確定的に消滅するには、債務者による時効の援用が必要である。
②契約解除	債務が履行されない等、一定の状態が発生したことで債権者がその意思表示によって契約の効力を一方的に廃棄するもの。解除により契約は遡って消滅し、債権は消滅する。
③法律行為の取消し	制限行為能力者の法律行為や詐欺により行われた法律行為を最初から行われなかったものとする債務者の行為。取り消されるまでは一応有効な債権が、取消しがなされると遡って消滅する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

債権者が債務者から何らかの協力を得た上で債権を回収する方法には、以下に挙げる方法がある。

1　代理受領

代理受領とは、例えば、甲社が乙社に100万円の代金債権を有している場合に、債務者である乙社がその取引先である丙社に対して有している150万円の代金債権の取立てを、乙社が甲社に委任する（甲社は、通常乙社から委任状を受け取る）ことをいう。委任を受けた甲社は、丙社から150万円を取り立てて受領し、そのうちの100万円については、甲社が乙社に有している債権の弁済に充て、残りの50万円を乙社に返却することになる。代理受領は、債権譲渡が禁止されている場合の迂回手段として活用されている。

代理受領では、甲社と乙社との間で取立てを委任する旨の契約が結ばれる（民法643条）。もっとも、甲社には取立て権限が与えられただけであり、そのことによって取立ての対象となる代金債権に関する法律関係は何ら影響を受けないため、丙社は、甲社から請求を受けた際

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

には、乙社に対して主張できる事由（同時履行の抗弁など）がある場合には、これを主張して支払いを拒むことができる。

2　代物弁済〔substitute performance〕

代物弁済契約は、例えば、債務者甲社が、債権者乙社との間で、乙社に対する100万円の代金債務の支払いに代えて、甲社が別の物（例えば、自動車1台）を乙社に提供し、これによって甲社の代金債務の支払いに代えて、100万円の債務を消滅させる旨の契約である（民法482条）。代物弁済契約は、甲社と乙社との合意によって成立する諾成契約であるが、100万円の債務を消滅させる効果が生じるのは、甲社が自動車1台を乙社に提供した時である。

なお、債権の弁済に代わる物件の提供が将来行われることを約束するのは、代物弁済の予約である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　所有権留保による商品返還

所有権留保とは、例えば売主である甲社と買主である乙社の間の商品（特に割賦販売）の売買において、商品の所有権は乙社が代金を完済したときに甲社から乙社に移転するものとし、代金が完済されるまでは甲社が商品の所有権を留保しておくことである（第9章第3節4参照）。もし、乙社が代金を支払わなかった場合には、甲社は自己の所有権に基づいて返還請求権を行使し、商品の返還を受けることになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　代物弁済および所有権留保による商品返還の注意点

代物弁済を受けるにあたっては、目的物の価値を過小評価することなどにより、不当に債務者の一般財産の減少を招き、その結果、他の債権者等から詐害行為取消権（民法424条1項、本章第2節2（2）参照）や否認権（破産法160条以下（第11章第1節7参照）、民事再生法127条以下、会社更生法86条以下）の行使を受けないように留意しなければならない。

また、所有権留保による商品返還を求める際にも、代物弁済と同様、詐害行為取消権や否認権の行使を受けないように留意しなければならない。

さらに、代金につき分割払いの約定がある場合において、代金がほとんど完済されているときに、所有権留保による商品返還の請求をすることは、債権者（所有者）の権利の濫用（民法1条3項）に当たるとされることもあるので注意が必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　準消費貸借契約の締結

準消費貸借契約とは、例えば代金債権の残債務相当額を、債務者が債権者から借り入れたという形式をとる契約であり（民法588条）、実質的には支払期限を延期するために行われる。

なお、準消費貸借契約締結前の旧債務に付された担保は、原則として、新債務（借入金債務）に移転すると解されている（大判昭8・2・24）が、保証人については、準消費貸借契約締結に際して改めて了承を得ておくことが望ましい。

5　債権譲渡〔assignment of claims〕

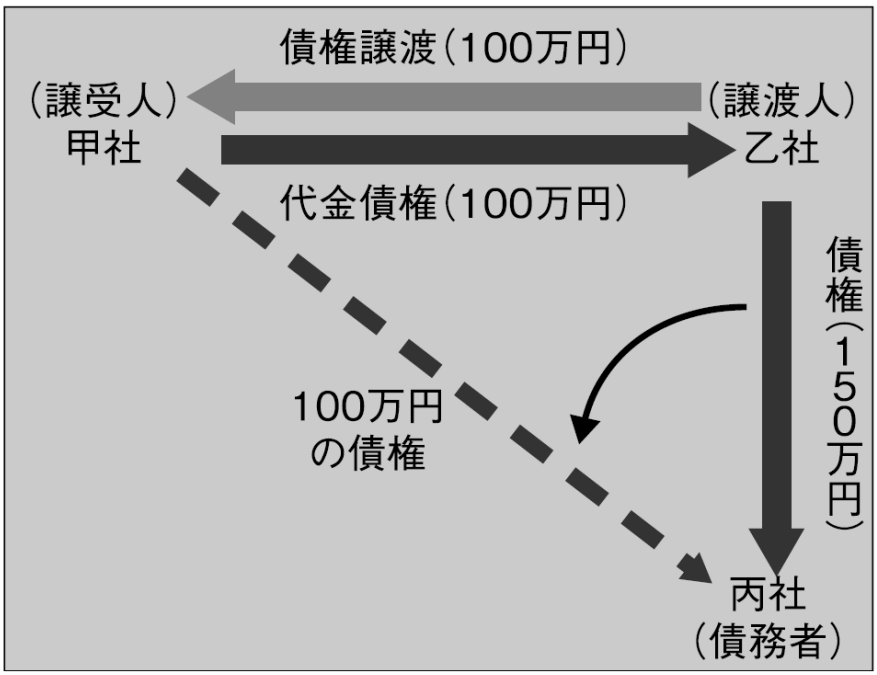
(1)債権譲渡とは

債権譲渡とは、債権をその内容を変更しないで譲渡人から譲受人に移転することをいう。

この債権譲渡を債権回収のための手段として用いることがある。例えば、甲社が乙社に対して100万円の代金債権を有し、乙社は丙社に対して150万円の債権を有

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

する場合に、甲社が乙社から丙社に対する債権150万円のうちの100万円の債権を譲り受ければ（その譲渡対価は、甲社の乙社に対する債権と相殺する）、丙社からその100万円を回収することによって、乙社から100万円の支払いを受けたのと同様の結果を得ることができる。



この債権譲渡による回収では、代理受領とほぼ同様の効果を得ることができる。しかし、代理受領では、丙社との関係で債権者であるのはあくまで乙社であるため、原則として、丙社が甲社に対する支払いを行わない場合に甲社が強制執行などにより

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

強制的に取立てを行うことはできない。これに対し、債権譲渡を受けていれば、丙社との関係では甲社が債権者となっているので、甲社は丙社に対して、強制的な取立て手段を直接行使することが可能となる。

ただし、丙社が倒産するなどして無資力となった場合など当該債権に伴うリスクを直接的に負うのは、代理受領の場合には乙社であるのに対し、債権譲渡を受けている場合には甲社となる。したがって、債権譲渡を受ける場合には、当該債権の債務者の信用状況について十分に調査、検討をした上で譲り受ける必要がある。また、債権譲渡がなされた後でも、債務者は、譲渡人に対して主張できる抗弁を譲受人に対して主張することができるのが原則であるので、当該債権について債務者から相殺や契約無効などの主張がなされる危険性がないかどうかについても、十分に確認する必要がある。

この債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意によってなされるので、債務者の協力を得て行う債権の回収方法といえる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　債権譲渡を利用した債権の回収

債権譲渡は、債権回収の手段として利用されることがある。債権譲渡を債権回収手段として利用する場合、もともとの債権者が、自己の債権の回収可能性等を考慮して計算した現在価値で第三者に売却することが多い。このとき、売却価格と債権の額面金額の差額は売却する（譲渡する）債権者の損失として計上される。したがって、一時的に損失を計上することとなっても、不良債権を早期に自社のバランスシートから切り離したいときなどに利用される。

特に、いわゆるサービサー（債権回収会社）と呼ばれる債権回収業者は、このような不良債権を一度に多数譲り受ける（購入する）「バルクセール」と呼ばれる方法を利用することがある。サービサーは債権回収の専門家であるから、当初の譲渡人である債権者よりも、購入金額以上で回収できる可能性が高い。そして、その場合、購入金額以上に回収できた金額は譲受人の利益となるため、サービサーのビジネスが成り立つのである。

このサービサーについては、債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）により、法務大臣による許可制、許可業者に対する規制・監督等がなされており、暴力団等の反社会的勢力の参入を排除している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（債権譲渡のポイント）

譲渡契約の当事者		譲渡人と譲受人
契約締結時の留意点		①債務者の信用状態を調査・確認する ②相殺・契約無効等の抗弁事由の有無を調査・確認する
対抗要件	債務者	通知・承諾、登記事項証明書の交付による通知
	第三者	確定日付のある証書による通知・承諾、債権譲渡登記（注）
譲渡通知		①通知者は譲渡人 ②通知の受取人は債務者 ③債務者は通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できる
承諾		①債務者が譲受人または譲渡人に対して表示をする ②債務者は承諾をするまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できる
譲受人が複数のときの優劣関係		確定日付のある証書による通知が異時到達のときは確定日付のある証書による通知の到達の先後による（承諾については確定日付のある証書による債務者の承諾の先後による）

（注）法人がする金銭債権の譲渡における対抗要件については、債権譲渡登記をもって確定日付のある証書による通知とみなす特例が設けられている（動産・債権譲渡特例法）。この場合、当該登記の日付が確定日付とされる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）債権はすべて譲渡の対象となるか。債権譲渡の対象とすることができない債権はあるか。

A）民法上は、債権は、原則として、譲渡することが認められているが、債権の性質や法律の規定により、譲渡が禁止されている債権がある。

（1）性質上譲渡が許されない債権

当事者間の特別の関係が債権発生の原因となっている場合や、債権者による特別の行為を要する場合は、債権を譲渡することができない。例えば、特定の人を教育する債権や特定の人の肖像を描かせる債権のように、債権者が変更すると給付の内容が全く変わってしまう債権が典型である。

（2）法律の規定により譲渡が禁止されている債権

扶養請求権（民法881条）や災害補償請求権（労働基準法83条2項）等は、明文で譲渡することが禁止されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3) 譲渡禁止特約のある債権

当事者(債権者・債務者)の合意により債権譲渡を禁止する特約を設けても、債権譲渡の効力は妨げられないのが原則である(民法466条2項)。ただし、当該債権譲渡禁止特約について悪意または重過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は履行を拒むことができる(民法466条3項)。この場合に、当該譲受人その他の第三者が、相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、履行がないときには、債務者は履行を拒むことはできなくなる(民法466条4項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)債権譲渡の当事者

債権譲渡は、譲渡人と譲受人の両者の合意によって行うことができる。譲渡についての債務者の同意等は不要である。

当事者(債権者・債務者)の合意により債権譲渡を禁止・制限する特約を設けても、債権譲渡の効力は、原則として妨げられない(民法466条2項)。ただし、当該債権譲渡禁止特約について悪意または重過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は履行を拒むことができる(民法466条3項)。この場合に、当該譲受人その他の第三者が、相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、履行がないときには、債務者は当該譲受人その他の第三者に対する履行を拒むことはできなくなる(民法466条4項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)債権譲渡の対抗要件〔requirement to duly assert against third parties〕

債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意によって行うことができる。しかし、この合意だけでは、外見上、債権譲渡が行われたか否かは不明であり、第三者からは誰が債権者であるのかを判別できないので、譲渡当事者以外の第三者に対して債権譲渡の効力を主張するには、法定の対抗要件を備えなければならない。この対抗要件は、①譲渡される債権の債務者に対する対抗要件と、②債務者以外の第三者(譲渡される債権を二重に譲り受けた者、譲渡される債権を差し押さえた者など)に対する対抗要件とに分けられている。

債権譲渡における対抗要件については、民法および「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(動産・債権譲渡特例法)に規定されている。それぞれの規定内容は次の通りである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（債権譲渡の対抗要件）

	債務者に対する対抗要件	債務者以外の第三者に対する対抗要件
民法	・譲渡人から債務者に対する通知（注） または ・債務者から譲渡人もしくは譲受人に対する承諾（民法467条1項）	・譲渡人から債務者に対する確定日付のある証書による通知 または ・確定日付のある証書による債務者から譲渡人もしくは譲受人に対する承諾（民法467条2項）
動産・債権譲渡特例法	・譲渡人もしくは譲受人から債務者に対して、登記官から交付を受けた登記事項証明書を交付して行う通知 または ・債務者から譲渡人もしくは譲受人に対する承諾 （動産・債権譲渡特例法4条2項）	・債権譲渡登記ファイルへの債権譲渡登記 この登記をもって、債務者以外の第三者について、民法467条2項の確定日付のある証書による通知がなされたものとみなされる。登記の日付をもって確定日付とされる。 （動産・債権譲渡特例法4条1項）

（注）譲受人が債務者に通知をしても有効な対抗要件とは認められないが、譲受人が譲渡人の代理人として債務者に通知をすれば、有効な対抗要件と認められる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）債権譲渡において、債権譲渡登記が活用されるのはどのような場合か。

A）動産・債権譲渡特例法による債権譲渡登記は、債務者に債権譲渡を知られたくない場合や、債務者が特定されていない場合に用いられる。

　債権譲渡につき最大の利害関係を有するのは、債務を弁済する義務を負う債務者である。そこで、民法は、債権譲渡の対抗要件を、債務者の認識に係らしめるため、債務者への通知または債務者の承諾とした。そのため、債権譲渡を行い、対抗要件を具備しようとすると、この事実を少なくとも債務者には知られてしまう。また、そもそも債務者が特定されていない債権については、譲渡したり、担保を設定することができないこととなる。

　そこで、動産・債権譲渡特例法が制定され、債務者の認識とは無関係に債権譲渡の対抗要件を具備することができるようになった。すなわち、債権譲渡登記がなされると、当該債権の債務者以外の第三者については、民法467条の規定による確定日付のある証

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

書による通知があったものとみなされ、第三者に対する対抗要件が具備される（動産・債権譲渡特例法4条1項）。

　なお、当該債権の債務者に対する対抗要件を具備するには、当該債権譲渡登記の登記事項証明書を交付して行う通知か、債務者から譲渡人または譲受人に対する承諾が必要となる（動産・債権譲渡特例法4条2項）。

（4）複数の対抗要件がある場合の優劣関係

　債権譲渡については、通知または承諾が対抗要件とされているため、この対抗要件が複数存在することがあり得る。

　債権の二重譲渡がなされた場合における複数の対抗要件の態様とそれぞれの効果は次の通りである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

<table>
<tr><td colspan="2">一方は確定日付のある証書による通知または承諾であり、他方は確定日付のある証書によらない通知または承諾である場合</td><td>・確定日付のある証書による通知または承諾を経た譲受人が優先する。
・第三者間（譲受人同士）の関係だけでなく、債務者との関係でも、確定日付ある証書によるもののみが対抗要件としての効力を有する（判例）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">確定日付のある証書による通知が複数ある場合</td><td>通知が異なる日時に債務者に到達した場合</td><td>確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日を基準として、その先後で優劣を判断する（判例）。</td></tr>
<tr><td>通知が債務者に同時に到達した場合</td><td>・いずれの譲受人も、債務者に対して譲り受けた債権の全額を請求することができる。
・債務者は、弁済などの債権消滅原因がない限り、複数の確定日付のある証書による通知がなされていることを理由に請求を拒むことはできない（判例）。債務者は、いずれかの債権者に対して全額を支払えば、以後当該債権の支払いについて免責される。</td></tr>
<tr><td>確定日付のある証書による承諾が複数ある場合</td><td colspan="2">承諾がなされた日を基準として、その先後で優劣を判断する（判例）。</td></tr>
</table>

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(5)債権譲渡の効果

債権譲渡がなされると、譲受人が当該債権の債権者として権利を行使することができ、譲渡人は、債権者としての権利を失う。譲受人が自らの権利を債務者あるいは第三者に対して主張するには、上述の対抗要件を備えることが必要である。

債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に主張することができる。具体的には、譲渡人に対して主張することのできる同時履行の抗弁権や、契約の無効、取消し、あるいは相殺の抗弁などを債権譲渡がなされた後も、譲受人に対して主張することができる(民法468条・469条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　電子記録債権

(1)電子記録債権法

事業者間における決済手段や資金調達の手段の1つである約束手形は、一定の様式に従って作成しなければならず、また、印紙税負担が大きいことや、紙媒体を利用することで紛失というリスクがあることなどから、その利用は減少してきている。また、事業者間における資金調達については、売掛債権を譲渡する方法もあるが、債権の存在・発生原因・債務者の支払能力を確認することが難しく、二重譲渡のリスクもあるため、売掛債権を活用して資金調達をするのは困難である。

このような状況のもとで、事業者の資金調達の円滑化等をいかに図るかという観点から、電子記録債権法が制定・施行されている。

(2)電子記録債権法の内容

電子記録債権法は、電子的な記録によって権利の内容を定め、債権の取引の安全・流通性の確保と利用者保護の要請に応えることをその内容としている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

具体的には、次のような特徴を備えているものである。

① 電子記録債権の性質　記録原簿への電子記録を発生・譲渡の効力要件とする金銭債権であり、記録原簿の記録により権利の内容が確定される。
② 取引安全の保護　善意取得や人的抗弁切断の制度が認められ、支払いについても記録原簿上の債権者への支払いにつき支払免責の制度を設けている。
③ 電子記録保証の制度　手形における裏書人の保証に相当する制度として、手形保証類似の独立性を有する電子記録保証の制度を設けている。
④ 質権　　電子記録債権を目的とする質権の制度を設けている。

電子記録債権を利用した決済サービスとして、「電子手形」や「でんさい」がある。

電子債権記録機関については、主務大臣が、業者から申請を受け、その業者の財政的基盤や業務遂行能力を勘案して電子債権記録機関としての指定をし、その監督を行う。また、電子記録債権が金融商品として取引される場合には、金融商品取引法が適用される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《債務者の協力を得て行う債権の回収方法》

債務者の協力を得て行う債権の回収方法	利用される場面	注意すべきポイント
①代理受領	債権譲渡が禁止されている場合の迂回手段	債権者と債務者間に取立委任の契約が必要
②代物弁済	特定物件の提供を債務者ができる場合	他の債権者により詐害行為取消権・否認権を行使されないこと
③所有権留保による商品返還	主に割賦販売取引	詐害行為取消権・否認権を行使されないこと 債権者の権利の濫用とならないこと
④準消費貸借契約の締結	支払期限の延期	原債務の保証人について契約締結に際しては改めて了承を得ること
⑤債権譲渡	債権者が自己の債権を保全・回収するため、債務者が第三債務者に対して有している売掛金債権等を譲り受ける	相殺・契約無効等の抗弁の有無を調査確認すること 対抗要件を具備すること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

6　債務引受

(1)債務引受とは

債務引受（さいむひきうけ）とは、契約によって、債務を、その同一性を維持したまま、債務者から新たな債務者（引受人（ひきうけにん））に移転させることである。

債務引受がなされると、引受人は、債権者に対して当該債務を履行する法律的な義務を負う。例えば、債権者は、当該債務が履行されない場合、引受人の財産に対して強制執行をすることができる。

債務引受には、もとの債務者（原債務者）の義務の存続の有無によって、併存的債務引受と免責的債務引受がある。

(2)併存的債務引受

併存的債務引受とは、引受人が原債務者とともに債務を負う形の債務引受であり、債権者からみると、債務の履行義務を負う者が1人増えるという結果になる（重畳的債務引受ともいう）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

この併存的債務引受は、債権者、原債務者および引受人の三者の合意による場合はもちろん、債権者と引受人、さらには原債務者と引受人の二者の合意によっても成立する（民法470条2項・470条3項）。併存的債務引受の場合には、上述の通り債務の履行義務を負う者が1人増えるだけであり、債権者にとって不利益な結果が生じるものではなく、債権者の意思を介在させなくてもよいと考えられているからである。そして、この場合の原債務者と引受人との関係は、連帯債務関係となるが（民法470条1項）、当事者間に合意がある場合には、その合意の内容によって定まる。原債務者と引受人との間の内部的な負担割合は当然に平等とされるのではなく、当該併存的債務引受がなされた具体的状況に応じて判断される。

併存的債務引受では、従来の債務は存続していることから、従来の債務についての保証や担保権なども存続することになる。

なお、当事者の合意内容からは、併存的債務引受か免責的債務引受かが明確でない場合には、特段の事情がない限り併存的債務引受と解すべきとされている（最判昭41・3・1）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)免責的債務引受

免責的債務引受とは、債務引受が行われた結果、引受人のみが債務者となり、原債務者は、当該債務を免れるという効果が生じる形態の債務引受である(民法472条1項)。従来の債務者(原債務者)に代わり、引受人のみが当該債権にかかる債務者となる。

この免責的債務引受については、債権者、原債務者および引受人の三者の合意による場合、あるいは債権者と引受人の二者の合意による場合に成立する(民法472条2項)。また、債務者と引受人の二者の合意により成立させることもできるが、債権者の承諾が必要である(民法472条3項)。

免責的債務引受がなされると、原債務者は、当該債務について債権者との関係で免責され、引受人のみが当該債務の履行義務を負う(民法472条1項)。

また、免責的債務引受がなされた場合、もとの債務に付されていた担保権や保証は、あらかじめまたは同時に引受人に対してする意思表示により移転することができる(民法472条の4)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《債務引受の種類》

表中の引用条文はすべて民法上のものである。

	併存的債務引受	免責的債務引受
基本的効果	債務者と引受人との連帯債務となる(470条1項)	引受人が債務者と同内容の債務を負担し、債務者が自己の債務を免れる(472条1項)
成立要件	・債権者と引受人となる者との契約(470条2項) ・債務者と引受人となる者との契約(債権者が承諾した時に効力発生)(470条3項)	・債権者と引受人となる者との契約(債権者が債務者に通知した時に効力発生)(472条2項) ・債務者と引受人となる者との契約および債権者の承諾(472条3項)
引受人の抗弁等	・引受人は、債務者の債権者に対する抗弁を債権者に対して主張できる(471条1項) ・引受人は、債務者が債権者に対する取消権または解除権を有するときに、これらの権利行使により義務を免れる限度で債務の履行を拒絶できる(471条2項)	・引受人は、債務者の債権者に対する抗弁を債権者に対して主張できる(472条の2第1項) ・引受人は、債務者が債権者に対する取消権または解除権を有するときに、免責的債務引受がなければこれらの権利行使により義務を免れることができた限度で債務の履行を拒絶できる(472条の2第2項)
担保の移転		・担保権または保証は、あらかじめまたは同時に引受人に対してする意思表示によって移転できる(472条の4)

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　債務者の協力を得られない場合の債権の回収

この節で学ぶこと

　債権を回収する手続を取る必要が生じている段階では、回収に向けて債務者の協力を得られないことも多い。
　この節では、債権回収をするにあたり債務者の協力を得られないときの債権の回収方法に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

　相殺、強制執行の手続

1　相殺〔set-off〕

(1)相殺とは

　相殺は、債権債務の両当事者がお互いに相手方に対し同種の債権債務（例えば、金銭債権）を有している場合に、一方の当事者の意思表示で債権債務を対当額（同額）で消滅させることである（民法505条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)相殺の要件－相殺適状

例えば、甲社と乙社がそれぞれ相手方に対して金銭債権を有しており、甲社がこれらの債権債務を相殺するには、相殺をしようとする甲社の債権(自働債権)と相殺される側の乙社の債権(受働債権)とが相互に相殺するのに適した状態(相殺適状)にあることが必要である(民法505条1項)。

相殺適状であるといえるためには、次の要件を充たしていることが必要である。

①債権が対立していること(注)	相互に相手方に対する債権を有することを要し、原則として他人の有する債権を自働債権として相殺することはできない。
②双方の債権が同種の目的を有する債権であること	例えば、金銭の支払いを目的とする債権と、商品の引渡しを目的とする債権とを相殺することはできない。
③双方の債務が弁済期にあること	民法上、自働債権と受働債権の双方とも弁済期が到来していることが必要である。 ただし、自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が未到来であっても、受働債権の債務者(相殺しようとしている側)は、期限の利益を放棄することによって(民法136条2項)、期限到来前でも弁済することができるため、相殺が可能である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

④双方の債権が性質上相殺を許すものであること	債務の性質が相殺を許さないときは、相殺をすることはできない（民法505条1項但書）。例えば、自働債権に対して相手方（債務者）が抗弁権（同時履行の抗弁権、保証における催告・検索の抗弁権など）を有するときには、相殺をすることはできない。また、反対債権の取得時期によっては相殺が認められないことがあるので注意が必要である（破産法71条）。

（注）他人が相手方に対して相殺適状にある反対債権を有する場合に、自己がその限度で履行を拒絶することが認められることがある（民法439条2項・457条3項）。
また、他人に対して有する債権をもって、相手方に対し相殺をもって対抗することができる場合がある（民法443条2項・463条1項・469条）。

（3）相殺の方法と効果

相殺は、相殺しようとする者が相手方に相殺する旨の意思表示をすることによって行う（民法506条1項）。意思表示を受けた側の同意は不要である。相殺の通知は、後日の証拠として利用でき、また通知した日が立証できるように、配達証明付内容証明郵便で行うことが望ましい。

相殺の意思表示が適法に行われた場合、双方の債務が対当額で消滅する（民法505条1項本文）。また、相殺の意思表示は、相殺適状が生じた最初に遡ってその効力を生じる（民法506条2項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4)相殺の禁止

相殺をするためには、相殺そのものが法律上可能でなければならない。法律の規定により相殺が禁止されている場合(民法509条～511条、会社法208条3項等)には、相殺が制限される。

また、当事者間で相殺を禁止または制限する特約(相殺禁止特約)をすることができる。ただし、第三者との関係では、第三者が相殺禁止特約につき悪意または重過失がある場合に限り、相殺禁止特約を対抗することができる(民法505条2項)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（相殺が法律により禁止されている場合）

禁止される場合	趣旨・理由等
受働債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償債権であるとき（民法509条1号）	悪質性の高い不法行為の被害者に現実の弁済を受けさせ、また、不法行為の誘発を防止するのが目的である。 例えば、債務を履行しない債務者に故意に暴行を加えその損害賠償債務とその債権を相殺しようとする場合がこれに当たる。
受働債権が人の生命または身体の侵害による損害賠償債権であるとき（民法509条2号）	生命または身体を侵害された被害者には現実の弁済を受けさせる一方、例えば、当事者双方の過失に起因する同一の交通事故によって生じた物的損害については相殺を認めた方が簡便であることから、相殺禁止の対象を制限する趣旨である。
受働債権が差押禁止の債権であるとき（民法510条）	債権者に現実の弁済を受けさせる趣旨で受働債権の差押えが禁止されている場合は、これを受働債権として相殺することはできない。 扶養料・俸給・恩給・扶助料（民事執行法152条、恩給法11条、生活保護法58条）等がこれに当たる。
受働債権が差押えを受けたとき（民法511条）	差押えを受けた債権の債務者（第三債務者）は、差押えの後に取得した債権を自働債権として相殺することはできない。 差押えを受けた債権について、差押えの後に取得した債権での相殺を許すと債権差押えの実効性が損なわれるからである。
受働債権が株式払込請求権であるとき（会社法208条3項）	会社に対する債権との相殺をもって資本金を払い込むことはできず、払込金額の全額を支払わなければならない。 株式会社における資本充実・維持の原則の具体的現れの1つである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）当事者間の合意によって、相殺をすることはできるか。

A）民法上、相殺は、相殺をしようとする者が、相手方に対する一方的な意思示によって行うことができ（民法506条）、意思表示を受ける側の同意は不要とされている。この民法上の相殺は、同種の債権・債務を相互に履行する手間を省く簡便な決済方法であり、同時に相殺をすることにより自己の債権を回収することができるという点で、一種の担保としての役割も有する（相殺の担保的機能）。

　これに対し、当事者が合意によって相互に有する債権・債務を消滅させること（契約）も、契約自由の原則により有効であるとされている。これを相殺契約という。民法上の相殺が一定の要件（相殺適状）を充たしていることが必要であるのに対し、相殺契約では相殺適状であることは不要であり、当事者間で合意した内容に従って相殺をすることができる。すなわち、相殺適状を充たさない債権や、民法上相殺が禁止されている債権であっても、相殺契約によって消滅させることが可能である。また、相殺契約と同様に、当事者の

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

私的自治として相殺の予約契約も有効である。相殺予約には次の3類型がある。

①典型的 相殺予約	相殺契約の予約を行い、予約完結権の行使により相殺の効果を発生させる。
②停止条件付 相殺契約	当事者の約定により、将来一定の事実が発生したら、当事者の意思表示を待たずに当然に相殺の効力を発生させる。
③準法定相殺	法定相殺に関する相殺適状の発生を容易にする特約。例えば、差押えなどの一定の事由が生じたときは、自働債権については債務者は期限の利益を喪失し、受働債権については期限の利益を放棄して、当然に相殺適状が発生する特約である。 相殺契約そのものではなく相殺適状の緩和特約であるため、準法定相殺といわれている。銀行取引約定書には一般にこの旨の記載がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ポイント整理

《相殺による債権の回収》

相殺	法定相殺	①相殺適状にあること （要件）　ア）債権が対立していること イ）双方の債権が同種の目的 ウ）自働債権の弁済期の到来 エ）双方の債権が性質上相殺を許すものであること ②法律等により相殺が禁止されていないこと ③相殺の意思表示をすること
	相殺契約	相殺の方法・要件・効果を当事者の合意で決定する
	相殺予約	①典型的相殺予約：予約完結権の行使により効力発生 ②停止条件付相殺契約：一定事実の発生により効力発生 ③準法定相殺：相殺適状の緩和特約

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　責任財産の保全

債権を回収するという観点に立つと、債務者の一般財産（差押え禁止財産などを除く、強制執行の対象となり得る財産。責任財産ともいう）は債権者の最後の拠り所である。したがって、債権者にとって債務者の財産が適正に維持されることは、債権回収上極めて重要な意味を持つ。

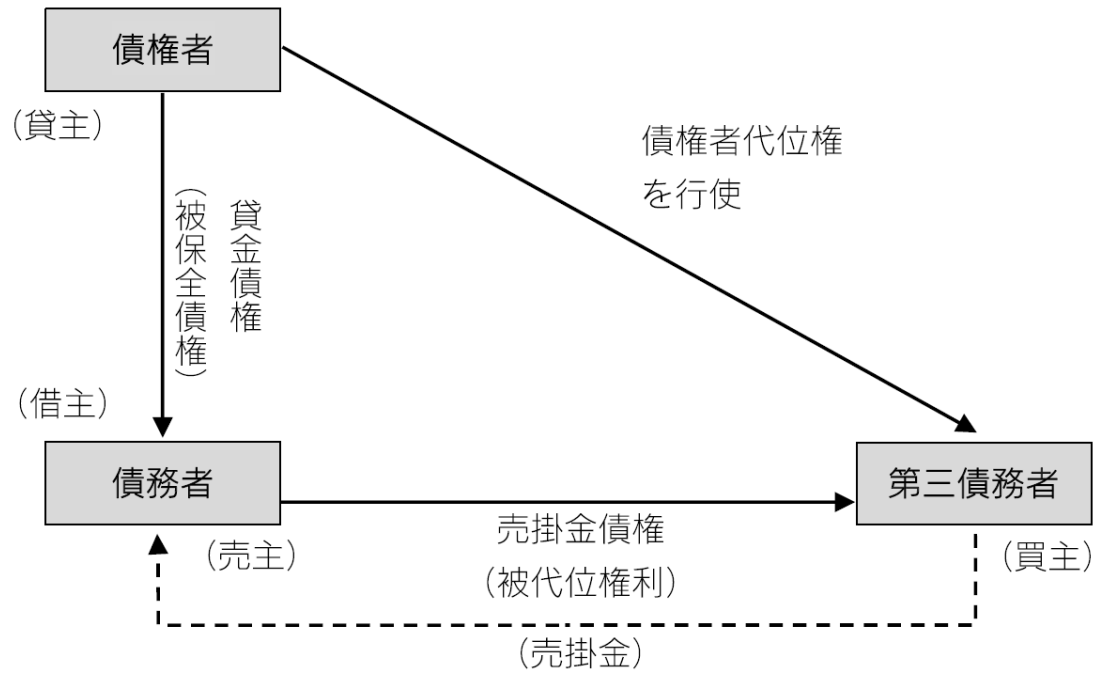
民法は、債権者にとって重要な意味を持つ債務者の一般財産につき、債務者がその減少を放置しているときは、債権者が債務者に代わってその減少を防止する措置を講じることを認め、さらに債務者が積極的に減少する行為をした場合は、その行為の効力を奪って減少を防止することも認めている。前者の制度を債権者代位権（民法423条）といい、後者の制度を詐害行為取消権（民法424条）という。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(1)債権者代位権〔obligee's subrogation right〕

ア)債権者代位権とは

債権者代位権とは、債務者が第三者に対して有する債権(例えば売掛金債権や不動産の登記請求権)の請求を怠っているとき、債権者が債務者に代わってその権利を行使することによって、債務者の責任財産を維持する制度である。例えば、債務者の売掛金債権の消滅時効の完成が目前に迫っており、債務名義を取得して売掛金を差し押さえるなどの手段を講じている時間的余裕がないときに、迅速に行使できる点でメリットがある。



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)債権者代位権の要件(民法423条)

被保全債権についての要件	①被保全債権が存在すること ②被保全債権が弁済期にあること
債務者についての要件	③代位債権者が「自己の債権を保全」する必要があること(債務者の無資力) ④債務者がいまだ権利を行使していないこと
被代位権利についての要件	⑤被代位権利が存在すること ⑥被代位権利が債務者の一身専属権、差押えを禁止された権利でないこと

なお、登記されていない建物の所有権保存登記のような保存行為については、弁済期前に債権者代位権を行使できる(民法423条2項)。

また、債権者が債務者に対して有する登記請求権を被保全権利として、債務者が第三債務者に対して有する登記請求権を代位行使する場合には、債務者が無資力である必要はないとされている(民法423条の7、判例)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)債権者代位権の行使とその効果

債権者代位権の行使は、裁判外でも裁判上でも可能である。債権者代位権は、債権者が債務者の財産権を管理する権限を取得し、債権者自らの名をもって行使するのであって、債務者の代理として行うのではない。ただし、相手方は、債務者が自らその権利を行使する場合に比して不利益な立場に立たされることはなく、債務者に対して有する抗弁権を主張できる(民法423条の4)。

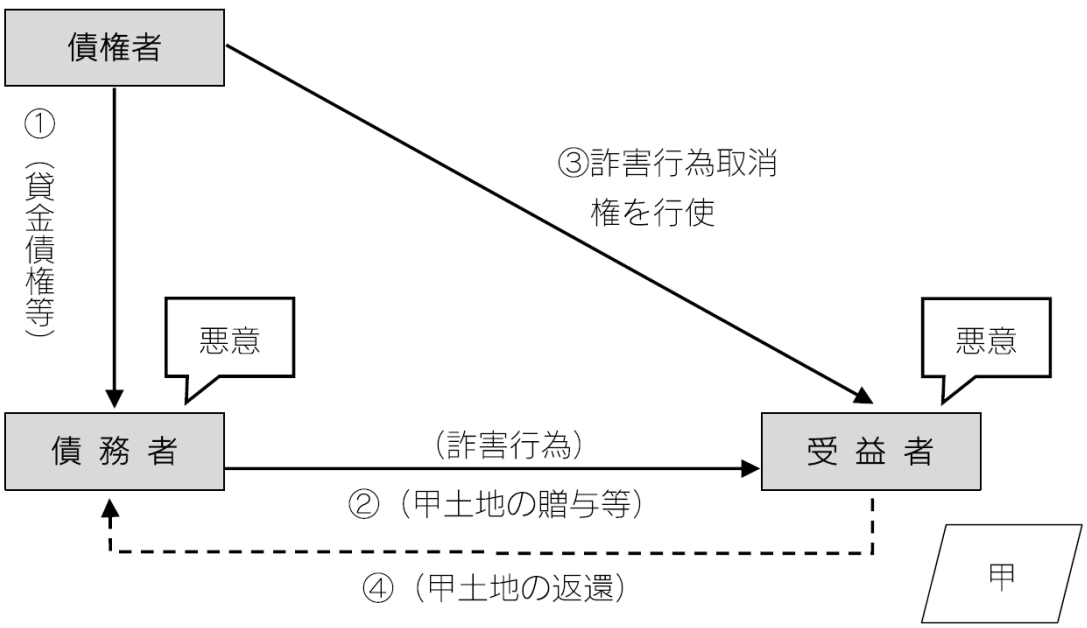
債権者代位権行使の結果、目的物は債務者に引き渡される。ただし、金銭または動産の場合には、債権者は当該金銭または動産を自己に引き渡すことを請求でき、債権者に対して金銭または動産の引渡しがなされたときは、被代位権利は、これによって消滅する(民法423条の3)。その結果、債権者代位権は、強制執行手続によらずに簡便に行使できる債権回収手段として機能することになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)詐害行為取消権〔obligee's right to demand the rescission of fraudulent act〕

ア)詐害行為取消権とは

詐害行為取消権とは、債務者が一般の債権者を害する目的で、特定の債権者に対して弁済や担保権設定、債務の免除などの法律行為を行った場合、その法律行為の取消しを債権者が裁判所に請求する制度である(債権者取消権ともいう)。



(注)「受益者」とは、詐害行為によって利益を受けた者である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)詐害行為取消権の要件(民法424条)

債権者側の要件		①被保全債権が存在すること ②被保全債権の発生原因が詐害行為前に成立したこと
債務者側の要件		
	客観的要件	③財産権を目的とする行為であること ④行為が債権者を害するものであること(債務者の無資力)
	主観的要件	⑤債務者が債権者を害することを知って行為をしたこと
受益者・転得者側の要件		⑥受益者(詐害行為によって利益を受けた者)は詐害の事実を知っていること 転得者(受益者に移転した財産を転得した者)がいる場合は受益者と転得者が詐害の事実を知っていること(民法424条の5) 受益者は詐害の事実を知らなかったことを、転得者は受益者と転得者がともに詐害の事実を知らなかったことを証明しなければならない

上記の要件を充たすかどうかは、詐害行為の類型によって異なっている(民法424条の2～424条の4)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（詐害行為の類型と該当性）

対象となる行為	原　則	例　外
相当の対価を得てした財産の処分行為（民法424条の2）	詐害行為に当たらない。	下記①～③すべてを充たす場合、詐害行為に当たる。 ①財産の種類の変更により隠匿等債権者を害することとなる処分（隠匿等の処分）をするおそれを現に生じさせるものである ②債務者が行為時に隠匿等の処分意思を有していた ③受益者が行為時に債務者の上記意思を知っていた
特定の債権者に対する担保供与、債務消滅に関する行為（民法424条の3）	詐害行為に当たらない。	（その1）下記①②を充たす場合、詐害行為に当たる。 ①当該行為が債務者が支払不能の時に行われた ②債務者と受益者が通謀して他の債権者を害する意思を有していた
		（その2）下記①～③すべてを充たす場合、詐害行為に当たる。 ①当該行為が債務者の義務に属せず、またはその時期が債務者の義務に属しない ②当該行為が債務者が支払不能になる前30日以内に行われた ③債務者と受益者が通謀して他の債権者を害する意思を有していた
過大な代物弁済等（民法424条の4）（注）	詐害行為に当たる。	受益者が債権者を害することを知らなかった場合、詐害行為に当たらない。

（注）積極財産を無償または不当な廉価で譲渡する行為は詐害行為の原則的な行為であり、本類型と同じ要件で詐害行為該当性が判断される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）詐害行為取消権における詐害行為とは、具体的にどのようなものか。

A）以下、詐害性の強い行為から順に、詐害行為を説明する。

①無償譲渡行為

積極財産を無償または不当な廉価で譲渡する行為は、債務者の責任財産を不当に減少する行為として詐害性が強いといえる。

②担保権の設定

判例によれば、担保権の設定は、当該債権者に優先弁済を得させることであり、詐害行為に当たるとされている（最判昭35・4・26）。ただし、新たに担保権を設定して金銭を借り入れた場合、それが生活資金や子供の教育費を得るためであれば、詐害行為にならないとされている（最判昭42・11・9）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

③財産の売却

判例によれば、不動産売却は価格が相当でも詐害行為になるとされる。不動産を現金に換価すると、他の財産に混入して把握が困難となるからである。ただし、判例の立場は、行為の詐害性について、動機も考慮して、抵当権を消滅させるための弁済資金を調達することを目的とした場合には詐害行為とならないとしたり（最判昭41・5・27）、適正価格での売却も一部債権者と通謀して行われると詐害行為となるとしている（最判昭39・11・17）。

④債権者への弁済

判例は、一部債権者への弁済は原則として詐害行為にならないとしつつ（最判昭33・9・26）、通謀等の害意があれば詐害行為性を認めている。

代物弁済については、弁済の一態様として捉えれば同様であるが、本来債務の本旨に従った弁済ではないこと、債務者に代物弁済をなすか否かの自由があることから、あえて行えば詐害性は強まる（最判昭48・11・30）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)詐害行為取消権の行使

詐害行為取消権を行使するには、裁判所に訴訟を提起する必要がある(民法424条1項)。詐害行為取消訴訟の相手方(被告)は受益者または転得者のみであり、債務者は被告とならない(民法424条の7)。

エ)詐害行為取消権の効果

詐害行為取消権の効果は、詐害行為の取消しと財産の取戻しである(民法424条の6)。

取消しの効果は、訴訟の原告(債権者)、被告(受益者・転得者)だけでなく、訴訟の当事者ではない債務者および債務者に対するすべての債権者に対しても生じる(民法425条)。

また、財産の取戻しは、現物の返還を原則とするが、現物の返還が困難なときには、価額の償還(金銭での支払い)を請求することができる(民法424条の6)。取消しの範囲は、債権者の債権額が限度となるが、目的物が分割不可能な場合にはすべてを取り消すことができる(民法424条の8)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

詐害行為取消権は、債務者の責任財産の保全を目的とするため、目的物は債務者に返還するのが原則である。ただし、金銭と動産の場合には、債権者への直接の引渡しを請求することができる（民法424条の9）。

したがって、目的物が不動産の所有権であれば登記名義を債務者に戻し、債権者は登記名義が債務者に戻った時点で強制執行手続をとることとなる。他方、金銭の場合、債権者は当該金銭を自己に引き渡すことを請求でき、自己の債権と債務者に対する引渡債務とを相殺することができる。

債務者との代物弁済契約や債権譲渡契約によって債権を回収する場合は、それに対して他の債権者から詐害行為取消権を行使される可能性があるので、代物弁済の目的物を適正に評価するなどの注意が必要である。

また、詐害行為取消訴訟を提起する場合、受益者・転得者に移転した財産がさらに転々流通すると、たとえ債権者が勝訴してもその後の強制執行などの実効性が乏しい。そこで債権者は、同訴訟の提起に先立って、受益者・転得者の手元にある、もともと債務者のものであった財産について、処分禁止の仮処分を申し立てるのが一般的である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　強制的回収

(1)債権回収のための事前措置

債務者が任意(自主的)に債務の弁済をしない場合、債権者としては最終的には強制執行手続によって債権の回収を図ることになる。しかし、債権者が訴訟その他の手続を進めた後、債務者の財産を差し押さえ、競売によって換価するまでには相当の期間を要する。その間に、債務者が所有財産を処分等していると、いざ強制執行しても、債権回収に充てる財産がまったく残っていないという事態も起こり得る。

したがって、債権者は、将来の強制執行に備えて、債務者の財産の散逸・隠匿を防止しておく必要がある。このような債権回収上の必要から利用されるのが、仮差押え・仮処分(両者を合わせて、民事保全手続あるいは保全処分ということがある)等の手続である。

ア)仮差押え〔provisional seizure〕

仮差押えは、金銭債権につき、債務者の財産の現状を維持しておかないと、後日強制執行が不能または著しく

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

困難となるおそれがある場合に（緊急性）、その執行を保全する目的で債務者の財産の処分を禁じる暫定的処置である（民事保全法20条）。

a. 仮差押えの要件

①被保全債権の存在

仮差押えによって保全される権利は、金銭債権でなければならない。金銭債権であれば、期限が到来している債権は当然のことながら、期限未到来の期限付債権や条件付債権も仮差押えの対象となる。ただし、期限未到来の債権等の場合は②の「仮差押えの必要性」に関する裁判所の判断は厳しくなる。

②仮差押えの必要性

債権者が仮差押えをしないで債務者の財産を現状のまま放置しておくと、債務者が財産を隠匿・処分するなどの執行妨害行為をして、将来債権者が強制執行しようとしても、それが不可能または著しく困難になるおそれがある場合に、仮差押えの必要性があるといえる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

b. 仮差押えの目的物件と手続

仮差押えでは、法律で禁止されていない限り、およそ財産的価値があり金銭に換えることが可能なものであれば、原則として、動産・不動産・債権などがすべてその目的物件となる。

仮差押命令は、当事者からの申立てにより、裁判所が行う（民事保全法2条1項）。また、仮差押えの執行は、申立てにより、裁判所または執行官が行う（民事保全法2条2項）。

c. 仮差押えの効果

債務者の動産・不動産に仮差押えが執行されると、債務者は仮差押えのなされた財産を自由に譲渡したり、担保に提供したりすることが禁じられる（動産につき民事保全法49条1項、不動産につき民事保全法47条1項）。

債権の仮差押えを受けた第三債務者が、これに反して債務者（仮差押債権者に対する債務者）に弁済しても、仮差押債権者が本執行（強制執行）に移行して当該債権の支払いを求めてきた場合、第三債務者は仮差押債権者に対してさらに支払わなければならない（すなわち、第三債務者は二重弁済をしなければならなくなる）（民事保全法50条1項、民法481条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ただし、仮差押えを行ったからといって、仮差押債権者は本執行に移行した場合に仮差押えを行った物件から、他の債権者よりも優先して弁済を受けられるわけではない。つまり、仮差押えには優先弁済権はない。

イ）仮処分〔provisional disposition〕

仮処分とは、金銭債権以外の債権を保全するために、裁判所によりなされる暫定的な措置である。

仮処分は、係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分とに分けられる（民事保全法23条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

	係争物に関する仮処分	仮の地位を定める仮処分
意味	金銭債権以外の権利の執行を保全するために、現状の維持を命ずる仮処分であり、対象となる財産の処分・移転が禁止される 処分禁止の仮処分と占有移転禁止の仮処分がある	係争中に生じている損害から債権者を保護するためになされる仮処分
例	建物の所有者が、建物の不法占拠者に対し、他の者の入居を阻止するために占有の移転を禁止する	解雇の効力を争う労働者が、使用者に対し雇用契約上の地位を有することを仮に定めてもらう
要件	現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあること、または権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあること	争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるため必要であること
手続	申請・執行手続は、基本的に仮差押えの場合と同じ	

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　民事保全手続の流れ

民事保全手続は、債務者の財産の散逸・隠匿を防止し、将来の債権回収（強制執行）を容易にするために行われる手続である。手続の流れは、次の通りである。

手続の流れ	概　　要
申立て	管轄裁判所に、申立書および疎明資料の写し・資格証明書・固定資産評価証明書（不動産仮差押えの場合）等の添付資料を提出することによって行う。
審理	手続の迅速性の要請から、書面審理もしくはそれに加えて申請当事者の審尋（面接）によって裁判が行われることが多い。審理によって、裁判官に被保全権利の存在および保全の必要性について、一応その存在が確からしいとの心証が形成されれば（疎明）、保全命令が発令される。
保証金の納付	保全命令の発令・執行に際しては、債務者がその保全命令の執行によって被ることがある損害を担保するために、債権者は担保（保証金）を供託すべきこととされるのが通常である（民事保全法14条1項・4条1項）。担保（保証金）として認められるのは、通常は現金、登録国債または銀行保証である。金額は、目的物によって異なるが、おおよそ請求債権あるいは目的物件の価額の10%～30%程度である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

保全命令・保全執行	保全命令は決定で行われる。保全執行は、債権者に保全命令が送達された日から2週間以内に実施されるが、送達前であっても実施することが可能である。 執行方法には、例えば不動産仮差押命令であれば、仮差押えの登記をする方法と強制管理の方法がある。

民事保全手続は、将来の強制執行を容易にあるいは確実にするための手続きである。強制執行をするためには、債権者が改めて強制執行の申立てをすることを要し、そのためには確定判決等の債務名義を取得することが必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）仮登記処分命令制度とは何か。

A）例えば、抵当権設定契約を締結したのに設定者が登記に協力しない場合、本来は権利者が義務者に対して抵当権設定登記手続請求の訴訟を提起し、勝訴判決を得て、これに基づいて権利者単独の設定登記を行うことになる。しかし、その間に義務者が他の第三者に抵当権の設定登記をしてしまえば、その第三者が先順位の抵当権を取得することになる。このような場合に、仮登記処分命令（不動産登記法108条）を得て、これによって仮登記を行い、自己の登記の順位を確保しておけば、仮登記には順位保全効があるので（不動産登記法106条）、第三者の抵当権は後順位のものとなる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)強制執行〔compulsory execution〕

ア)債権回収の最終的手段としての強制執行

債務者が任意に債務の弁済をしない場合でも、債権者が債務者の財産を勝手に持ち出すことや、処分することは禁じられていることから(自力救済の禁止)、最終的には、国家権力の関与により強制的に債権の回収を図ることになる。その手続が強制執行手続である。

強制執行は、申立てから発令までにある程度の時間を要する。そのため、強制執行手続の進行中に目的物が処分されるのを防ぐために、前述の仮差押え等の保全処分を検討する必要がある。

イ)強制執行の要件

強制執行の申立てをするには、強制執行を根拠付け正当化する書面等である債務名義(民事執行法22条)が必要である。

債務名義には、確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・調停調書・仮執行宣言付支払督促・強制執行認諾文言付公正証書等がある(第12章参照)。

なお、債務名義のみで強制執行することはできない。判決が確定する等して執行条件が成就するなど、執行力を備えている必要があり、この執行力の存在を証明する文書として執行文が必要である(民事執行法26条参照)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）公正証書はどのようなものか。

A）公正証書は、公証人が法令に基づいて、契約などの権利義務に関する事実について作成した書面または電磁的記録である（次のCOLUMNを参照）。

　債権はそのままでは強制執行ができない。しかし、債務者が公正証書において、直ちに強制執行を受けても異議がない旨を認諾していれば（強制執行認諾文言）、債務者に債務不履行があった場合、この公正証書に基づいて債権者は強制執行をすることができる。このような強制執行認諾文言が入った公正証書を、「執行証書」という。したがって、債権回収上、文書を公正証書にすることのメリットは、①公正証書の強い証拠力に加えて、②公正証書中に強制執行認諾文言を入れた場合の強制執行力、および③訴訟等によらずに債務名義を取得できる迅速性にある。

　なお、公正証書中の執行認諾文言によって強制執行することができるのは、金銭の一定額の支払い、または代替性のある物の引渡しである。土地や建物のような特定物の引渡しは、たとえ執行認諾文言があっても、強制執行できない。その場合は、即決和解手続（起訴前の和解手続）を利用することになる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　公正証書の電子化

2023年6月に成立した「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により公証人法が改正された。その目的は、公正証書の手続を全面的にデジタル化することにあり、債務名義となる執行証書、各種の契約書、および公正証書遺言を作成する際の手続が対象となる（2025年10月1日施行）。主な変更点は次の4点である。

1　オンライン嘱託

公正証書の作成を依頼する嘱託人は、公証役場へ行くことなく、インターネット（メール）での嘱託が可能となる。本人確認は、マイナンバーカード等を使用し、電子データに電子署名や電子証明書を付して行う。

2　ウェブ会議の利用

嘱託人が希望し、かつ、公証人が相当と認めれば、リモート方式のウェブ会議を利用して、陳述聴取や内容、真意の確認等を行うことができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　原本の電子化と電子サイン

公正証書の作成および保存は、原則として、従来の書面ではなく電子データ（PDFファイル）でなされる。嘱託人は、従来の押印に代えて、電子ペンでディスプレイなどに手書きで行うリモートの「電子サイン」を行えばよい。

4　公正証書の閲覧、正本・謄本の電子交付

公正証書は、紙でも電子データでも閲覧することが可能である。また、正本や謄抄本は、従来の書面交付に加え、メールの受信（クラウド経由のダウンロード）やUSBメモリ等への記録により、電子データとして受領できる。

電子化により、企業は、契約実務の時間短縮やコスト削減を期待できるが、メリットを享受するためには、パソコン（スマートフォンやタブレット端末は不可）や電子サイン用の機器、代表者等の電子証明書などを準備する必要がある。デジタル化に伴い手数料が変更される点にも注意が必要である。

なお、デジタル化に対応する指定公証人は、施行日以降、順次指定され、2025年中に完了予定であるが、当面は利用したい公証役場がデジタル手続に対応しているかの事前の確認が必要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ウ)強制執行の目的物件の種類

強制執行においては、法律で禁止されていない限り、およそ財産的価値があり換価可能なものであれば、動産・不動産・債権などがすべてその目的物件となる。

ただし、強制執行は債権者の執行債権の満足を図る制度であるから、その満足と執行費用の弁済に必要な範囲を超えて差押えをすること(超過差押え)はできない(民事執行法146条2項)。したがって、差押債権者の債権および執行費用の額が合計550万円で、債務者が300万円、400万円、500万円の債権を有していた場合、いずれか2つの債権しか差し押さえることができない。また、実務上は「請求債権額に満つるまで」という形で差押えの限度が差押債権の一部にとどめられることで、超過差押えを防止している。

また、債務者の生活保障や生業維持の要請から、一定の範囲の動産および債権については、差押えが禁止されている(差押禁止財産。民事執行法131条・152条)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）財産開示制度とは何か。

A）強制執行を困難にする大きな要素として、債務者の財産が把握できないという点が挙げられる。そこで、財産開示制度が設けられている（民事執行法196条以下）。財産開示手続の申立てをすることができるのは、執行力のある債務名義の正本（仮執行宣言付判決・支払督促、執行証書等を除く）を有する金銭債権の債権者、および債務者の財産について一般の先取特権を有する債権者である。申立てにあたっては、強制執行または担保権の実行における配当等の手続において完全な弁済を得ることができなかったことを証明するか、または知れている財産に対する強制執行を実施しても完全な弁済を得られないことを疎明する必要がある。財産開示手続が開始されると、債務者は期日に裁判所に出頭して自らの財産について陳述することになるが、債務者が期日に出頭しない場合、陳述すべき事項を陳述しなかった場合や、虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる（民事執行法213条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

エ）強制執行手続の流れ

強制執行は、執行目的物により、不動産執行、動産執行、債権執行に分かれている。

強制執行の申立ては、裁判所または執行官に対して行う。強制執行の取扱機関は、不動産や債権については裁判所、動産については執行官が担当する。

このうち、不動産執行（競売）の流れは、次の通りである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

① 執行の申立てをし、要件が整っていれば開始決定が下りる。

② 不動産登記記録に差押えの登記がなされ、不動産の所有者（債務者等）は、任意に処分できなくなる。

③ 物件の調査や評価手続・債権関係の調査手続が進行し、最低売却価格が決定される。（注）

④ その後、入札が行われ、売却許可が決定されれば、代金を納付する。

⑤ 代金納付のあと、配当手続が進行し、配当金の支払いが行われる

（注）不動産競売における暴力団員等の買受け防止のため、次の方策がとられる。

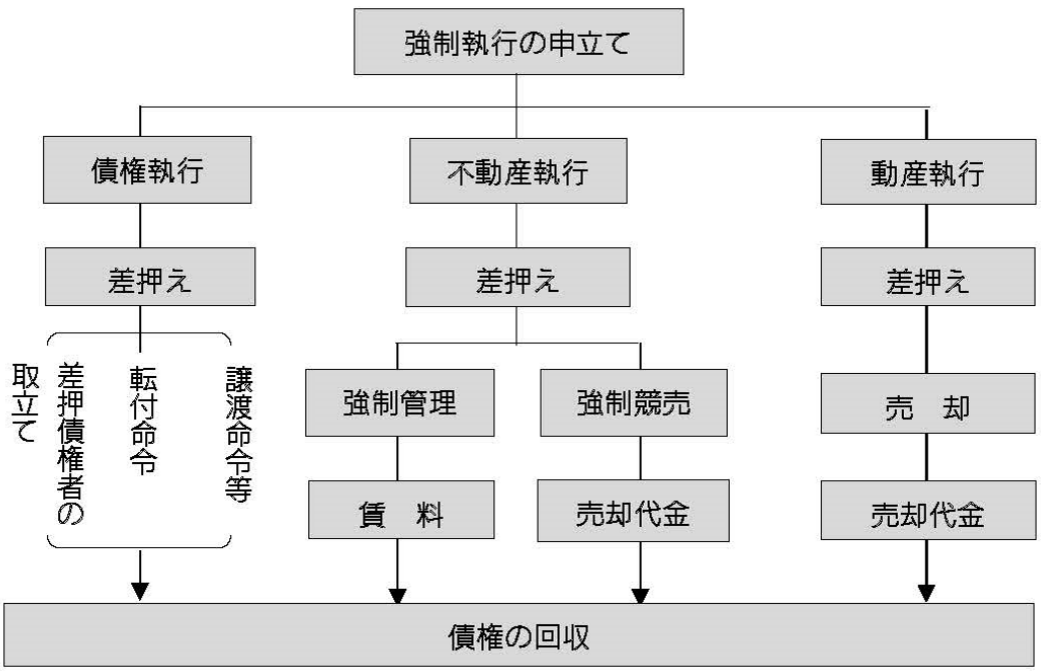
・買受け申出人は、暴力団員等（暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、法人で役員のうち暴力団員等がいるものを含む）に該当しないことまたは暴力団員等の指示に基づき買受けの申出をするのではないことを陳述する（民事執行法65条の2）。虚偽の陳述には、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される（民事執行法213条1項3号）。

・最高価額の買受け申出人が暴力団員等に該当するか否かを、裁判所から警察へ照会する（民事執行法68条の4）。暴力団員等に該当すること等が認められれば、裁判所は、売却不許可決定を出す（民事執行法71条5号）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、債権執行については、金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が送達された日から一定の期間を経過したときは、その債権を取り立てることができる（民事執行法155条）。また、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払いに代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令（転付命令、民事執行法159条）や、条件付債権や期限付債権などについて相当な方法による換価を命ずる命令（譲渡命令等、民事執行法161条）を発することができる。

（強制執行手続の概要）



© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）強制管理はどのような制度か。

A）不動産に対する強制執行の方法には、強制競売のほかに強制管理がある。

　強制管理は、差し押さえられた債務者の不動産を執行裁判所が選任する管理人に管理させ、それによって得た収益（賃料等）から租税公課を控除し、管理費を弁済し、その残余をもって債権を満足させる方法である（民事執行法93条）。

　強制管理は、強制競売のように不動産を売却しその代金によって満足を図るのではなく、不動産から得た収益で債権者を満足させる執行方法である。したがって、強制管理は、差し押さえた不動産を換金してしまうのではなく、ある程度長期にわたるとしても、管理収益に期待した方が有益な場合、例えば、賃貸マンション・貸ビルのように収益の上がる建物や、換金の困難な物件の場合に効果的である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

強制競売手続と強制管理手続の関係については、債権者は、不動産の強制競売または強制管理の一方を選択し、またはその双方を併用することができる。したがって、債権者がその双方を申し立てたときは、双方の手続が並行して進められることになる。しかし、当該不動産が売却によって移転したときは、債務者の不動産ではなくなるから、強制管理は認められなくなる。

なお、不動産に対する仮差押えによっても強制管理が認められる（民事保全法47条）。手続は、強制執行としての強制管理の場合とほとんど同じであるが、仮差押えの場合は管理人が第三者から取り立てた賃料等を債権者に配当することなく、保全される債権額に満つるまで供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出る点だけが異なっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

オ)配当手続

強制執行は、強制執行が取り下げられ、または無剰余による取消し(民事執行法63条)、執行不能となった場合を除き、配当手続をもって終了する。配当手続は、債務者の財産を強制的に売却して得た金銭を債権者に分配する手続である。

強制執行を申し立てた債権者以外の債権者は、法律上自動的に配当にあずかることができる一定の債権者を除き、すでに差し押さえられた目的物についてさらに配当を受ける権利が制限されている。そして、配当にあずかることのできる債権者は、すでに他の債権者の申立てにより進行している競売手続に参加し、配当要求をしなければ、配当にあずかることができない(民事執行法87条・140条・165条)。

複数の債権者がある債務者に対して債権を有している場合において、その中に強制執行の申立てをしている債権者がいるときには、それ以外の債権者は、上述の配当要求を行うほか、重複して差押えを申し立てる(二重差押え)こともできる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

	二重差押え	配当要求
意　味	ある債権者が強制執行手続の開始を申し立てて差し押さえている目的物について、他の債権者がさらに強制執行手続の開始を申し立てて差押えをすること	ある債権者の申立てにより開始されている強制執行手続に他の債権者が参加すること
共通点	先行の差押手続で配当を受けられる	
相異点	先行の差押えが取下げ・取消しで終了した場合、後行の差押えによって手続は維持される	先行の差押えが取下げ・取消しで終了した場合、手続は終了する（配当要求の効力も失われる）

カ）配当にあずかる債権者の範囲と手続

a. 債務者に対する金銭債権を主張して配当にあずかる者（一般債権者）

一般債権者でも、執行力のある債務名義の正本を有する者（有名義債権者）と執行力のある債務名義の正本を有しない者（無名義債権者）とでは、次のように大きく異なる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

	有名義債権者	無名義債権者
不動産	以下のいずれかの方法により配当を受けることができる。 ・二重差押え （民事執行法87条1項1号・47条） ・配当要求 （民事執行法87条1項2号・51条）	他の債権者の差押えの登記に先行して無名義債権者が仮差押えの登記を経ている場合 本案訴訟などにおいて勝訴するなど、権利が確定した段階で配当を受けることができる（配当要求不要）。 （民事執行法87条1項3号）
	債権者が強制執行しようとする不動産に仮差押えの登記をしており、それが他の債権者による差押えの登記に先行するときは、配当要求によらずに配当を受けることができる（民事執行法87条1項3号・民事保全法47条）。	他の債権者の差押え後に無名義債権者が仮差押えの登記を経た場合 配当要求が必要 （民事執行法87条1項2号）
債権	以下のいずれかの方法により配当を受けることができる。 ・二重差押え （民事執行法165条・144条3項・149条） ・配当要求 （民事執行法165条・154条1項）	原則として配当要求により配当を受けることはできない。
		無名義債権者が債権に仮差押えをした場合 本案訴訟などにおいて勝訴するなど、権利が確定した段階で配当を受けることができる（配当要求不要）。 （民事執行法156条2項3項・165条）
動産	動産に対する強制執行では二重差押えが禁止され、競合する動産執行事件は併合される（併合手続、民事執行法140条・125条）。	なし

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

b. 担保権を主張して配当にあずかる者（担保権者）

不動産に対する強制執行の場合、抵当権者、換価によって消滅する質権者、および特別の先取特権者は、競売申立ての要件を備えている限り二重差押えをすることができる（民事執行法188条・47条）。いずれの担保権も、設定登記が差押えの登記に先行していれば、自動的に配当にあずかり得る（民事執行法87条1項4号）。

債権に対する強制執行の場合、質権者は競売申立ての要件（民事執行法193条）を備えている限り二重差押えをすることができ、先取特権者は、二重差押えに加えて配当要求をすることができる（民事執行法154条）。

動産に対する強制執行の場合、一般債権者と同様、事件の併合がなされる（民事執行法192条・125条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　債権回収の基本的な流れ、手順

債務者が約定通り債務の履行をせず、当初の予定通りの債権の回収が困難となったとき、債権者は、次善の策として、ある時は債務者の協力をとりつけながら、またそれが不可能なときは強制的に債権回収を図る必要がある。そのためには、債務者の資産内容を的確に把握し、換価価値の高い資産を確保しておかなければならない。

その要領は次の通りである。

①貸借対照表（バランスシート）、損益計算書など、取引先の資産内容や負債内容を示す資料を入手する。
②債務者の再建に対する対応を検討するとともに、まず確保するべき資産は何かに着目する。
③同時に取引先の労使関係の実態も可能な限り調査する。

↓

現在価値・時価に基づくバランスシートを作成する。
→配当原資に関係のない資本金・諸積立金は考慮に入れない。
もっぱら配当原資中心のいわゆる整理バランスを作成する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD



①換価価値の高い流動資産から優先的に回収を図る。
②固定資産を保全・確保する。
　→土地・建物などの不動産につき、担保権等先順位の優先債権を控除してなお残余がある場合、可能であれば抵当権の設定・代物弁済契約などを行う。
③代表者の個人資産の確保を図る。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2023年の民事執行法等の改正

2023年6月、民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るため、「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（民事関係手続デジタル化法）が成立し、民事執行法等が改正された（一部の規定を除き、公布の日から5年を超えない範囲内で政令で定める日から施行）。

この法律は、2022年5月に成立した「民事訴訟法等の一部を改正する法律」によって、民事訴訟手続が全面的にデジタル化したことに引き続いて、民事訴訟以外の民事関係手続についても全面的なデジタル化を図るとともに、公正証書の作成に係る一連の手続について全面的なデジタル化を図るものである（第12章第3節「法改正・新法制定　2022年の民事訴訟法の改正」参照）。改正の概要は、次の通りである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　民事関係手続の主な変更点

(1)インターネットを利用した申立て等の実現

民事訴訟以外の民事裁判手続において、インターネットを利用して裁判所に申立てや資料の提出などができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができることとされた。

(2)期日におけるウェブ会議等の活用

民事訴訟にある期日(例:口頭弁論期日、審尋期日)においてウェブ会議が利用されるだけでなく、民事訴訟にない期日(例:債権者集会の期日、財産開示期日)についても、ウェブ会議等を利用して期日に参加することが可能とされた。

また、改正前の民事訴訟法にある遠隔地要件を削除するなどして、当事者等が遠隔地に居住していないケースでも電話会議等を利用することができると明確化された(2026年5月21日施行)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)判決等の事件記録の電子化

判決等の債務名義が電子データで作成されている場合に、債務名義の正本等の提出を省略することができる仕組みが設けられた(2026年5月21日施行)。

2　公正証書に係る一連の手続のデジタル化(2025年10月1日施行)

公正証書に係る一連の手続について、以下の通りデジタル化を図る改正がなされた。

(1)公正証書の作成の嘱託(申請)を、インターネットを利用して、電子署名を付して行うことが可能とされた。
(2)公証人の面前での手続について、嘱託人が希望し、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して行うことが選択できることとされた。
(3)公正証書の原本は、原則として、電子データで作成・保存することとされた。
(4)公正証書に関する証明書(正本・謄抄本)を電子データで作成・提供することを嘱託人が選択できることとされた。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD